

Régimen Legal de los Bancos de Datos:

Base de datos. Concepto.

El concepto de dato existe desde las más lejanas épocas. El término en sí se deriva de la raíz latina del verbo dar y significa aquello que destinado a entregarse. En función de ello, **podemos definir al dato como aquella porción de información destinada a su transmisión a los terceros.**

Si bien tradicionalmente se asoció el concepto de dato con contenidos alfanuméricos y el formato papel, no necesariamente esto es así. Así como hoy en día se entiende al documento como cualquier forma idónea de contener información, siendo indiferente cuál es el medio utilizado; gracias a los adelantos en los métodos de almacenaje, en la actualidad **un dato se libera tecnológicamente de la restricción impresa y por es por ello susceptible de expresarse, entre otras formas, mediante audio, vídeo o información digital.**

Esta última forma de almacenaje presenta problemas particulares derivados de un cambio de paradigma económico. Si bien tradicionalmente era posible la existencia de bases de datos, las mismas se encontraban restringidas en su creación y gestión por el medio empleado: El formato papel implicaba que la necesidad de importantes espacios físicos a los efectos del almacenaje, así como el entrenamiento de personal especializado en el recupero de la información como en la preservación de los documentos allí contenidos. Esta misma realidad física dificultaba en gran medida la posibilidad de compartir la información contenida en dos bases de datos diferentes, lo que impedía el entrecruzamiento de las mismas.

La digitalización de los bancos de datos mediante de incorporación de tecnologías informáticas permite no solo el acceso de la propiedad de un banco de datos a personas que anteriormente carecían de posibilidades materiales de ser titulares de una, sino, y lo que es más importante, la explotación en forma económicamente rentable de dicha información. Este fenómeno se expresa no solo en la baja del costo de la creación y mantenimiento de un banco de datos, sino asimismo, en la posibilidad de interrelación de la información contenida en dos bancos de forma tal de obtener una tercera base, la cual, si bien contendría elementos de las dos anteriores, funcionaría de forma autónoma a estas.

Frente a esta realidad, el derecho debe resolver dos interrogantes fundamentales: La primera es cuál es la información susceptible de tratamiento y en segundo lugar, cuáles son los límites que debe observarse en dicho tratamiento respecto a las informaciones autorizadas.

El problema desde el punto de vista del derecho constitucional y civil.

Los problemas derivados de la utilización de información se remontan desde mucho antes de la irrupción del ordenador. Si bien siguiendo a Ariés y Duby¹ podemos sostener que social y legalmente las diferencias establecidas

¹ Georges Duby y Philippe Ariés, "Historia de la vida privada", Taurus, 1992

en la edad moderna respecto a los aspectos privados y públicos de la existencia no se encontraban claros tanto en el mundo grecolatino como en el medioevo, ya en el renacimiento y particularmente en la obra de los filósofos ingleses de la época como Hobbes, Locke o Stuart Mill se puede encontrar una forma embrionaria en la noción del “*fuero íntimo*” como espacio restringido al accionar del estado.

A este respecto, el movimiento legislativo liberal posterior a la revolución francesa retoma la idea, asociándola a la idea de propiedad, de forma tal que la misma se transforma en una barrera para el poder estatal y un refugio para la burguesía que encontraba en el mismo un espacio de libertad, lejos de la injerencia de terceros.

Debemos esperar hasta fines del siglo XIX para encontrar la primera expresión teórica del principio de privacidad tal como hoy lo conocemos. Es en los Estados Unidos y con ocasión de un debate público respecto al límite del derecho de la prensa de publicar la información referente a las personas, que se elaboró el concepto de privacidad como límite a dicho accionar². A este respecto, se interpuso al derecho de información un nuevo derecho, nacido de la necesidad de proteger la esfera íntima de los sujetos de derecho.

Nuestra constitución nacional recepta el principio de privacidad en una concepto liberal en su art. 19 al expresar que “*Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o la moral pública, ni perjudiquen a los terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados*”

Es clara que la finalidad del artículo es la limitación del accionar del estado frente a la esfera íntima de un individuo. En este sentido, el precepto constitucional se relaciona en forma directa con la concepción liberal de la intimidad. El problema que nos presenta este artículo es definir qué consideramos como acciones privadas de los hombres y cual es el grado de efecto que pueden tener las mismas en un tercero. A este respecto, si consideramos que las conductas protegidas son solo aquellas realizadas a puertas cerradas, y si el efecto requerido es la simple violación de un standard moral determinado, nos encontraremos frente a una interpretación restrictiva del instituto, mientras que si sostenemos la indiferencia de lugar de realización, de forma tal que las acciones incluyan aquellas realizadas en público pero que carecen de efectos respecto a los terceros, nos encontraremos frente a una tesis amplia. A este respecto y con el objeto de clarificar la cuestión analizaremos la evolución de la Corte Suprema acerca de la criminalización de la tenencia para consumo personal.

En el mes de agosto de 1986 en oportunidad de sentenciar en el caso “*Bazterrica*”, la Corte Suprema entendió que pena el consumo personal de estupefacientes era violación del principio de intimidad consagrado por el art. 19 de la constitución nacional. En dicho caso la corte entendió que las acciones realizadas en la vía pública (en el caso en concreto la tenencia de cocaína) estaban amparadas por la protección del art. 19, atento el hecho que en modo alguno importaban un perjuicio para terceros.

Sin embargo, años después, y con otra composición, el tribunal cambió el criterio en el caso “*Montalvo*” de 1990, sosteniendo que el consumo de marihuana en lugares públicos constituía un infracción punible, por considerar

² Samuel Warren y Louis Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, 1890

que la tenencia para consumo personal constituía un delito de peligro abstracto y que el mero ejemplo constituía un posible daño a los terceros, los cuales podían ser tentados al consumo de la sustancia.

En el primer caso, nos encontramos frente a una tesis amplia del derecho a la privacidad, mientras que en el segundo caso, la misma es restringida. La diferencia fundamental es en que consideramos daño a terceros: En el primer caso, la ausencia actual del mismo constituyó soporte suficiente para declarar la inconstitucionalidad, mientras que en el segundo caso, el mero peligro o incluso el rechazo de la media de la sociedad de la práctica en cuestión permitió considerar que el acto no estaba protegido por la constitución.

Otro antecedente fundamental en referencia la intimidad fue el caso “Ponzetti de Balbin” fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 11 de diciembre de 1984, en el cual se discutió la existencia de responsabilidad derivada de la publicación de fotografías de los últimos momentos del líder de la Unión Cívica Radical, Dr Ricardo Balbin.

En dicho fallo, la corte sostuvo que *“El derecho a la privacidad e intimidad encuentra su fundamento constitucional en el art. 19 de la constitución nacional. En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones de familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.”* Asimismo, el fallo extendió el concepto de la intimidad protegida por el art. 19 CN a las acciones de los particulares al sostener que *“El derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica... sino también otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento...”*

Como podemos ver, la constitución a través de interpretación jurisprudencial del art.19 de la constitución nacional, la corte realizó la recepción de no solo el aspecto vinculado a la limitación del accionar estatal frente al sujeto, postura que podemos considerar de corte liberal clásico, sino inclusive los aspectos básicos de la teoría de la privacidad tal como fue expuesta en los Estados Unidos por Warren y Brandeis.

En un mismo sentido la incorporación del art. 1071 bis en el código civil trabaja en el mismo sentido que la doctrina sentada en el caso Ponzetti de Balbin al ordenar que la intromisión arbitraria en la vida de una persona, ya sea mediante la publicación de su imagen, correspondencia, costumbres o cualquier otro mecanismo de violación de la privacidad será considerado como una acto ilícito civil y corresponderá entonces una acción a los efectos de no solo el cese de la intromisión sino también la posibilidad de lograr la retractación mediante la publicación de la sentencia o incluso la imposición de daños y perjuicios.

Respecto al carácter arbitrario de la intromisión, la misma se refiere a la necesidad que carezca de la una causal de orden público o protección legal que la justifique. Así, la Cámara Nacional entendió que la publicación de información respecto a la actuación profesional en la práctica privada de una

persona de actuación pública no constituía una violación del art. 1071 bis, por considerarse que concurría un interés superior como era el derecho de informar respecto a la cosa pública.

El art. 43 de la constitución nacional:

La reforma constitucional del año 1994 incluyó dentro del art. 43 la consagración de una serie de garantías constitucionales que se encontraban consagradas en la jurisprudencia y la legislación, como el amparo.

Al mismo tiempo, en su tercer párrafo el art. incorpora la figura del habeas data como garantía constitucional. Esto presenta una novedad importante, ya que a diferencia del amparo, esta figura no tenía una consagración jurisprudencial anterior.

Ello, no quiere decir que no existan antecedentes a nivel de la legislación comparada. La constitución de Brasil en el año 1988 incorpora el instituto, lo mismo que la legislación y constituciones europeas, de países como Francia, España o Alemania. Asimismo, en el derecho interno, el instituto se encontraba consagrado en la constituciones provinciales modificadas a partir de la vuelta de la democracia.

El texto constitucional dice: *“Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referida y de su finalidad, que consten en registros y bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en el caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes periodística”*

La formulación constitucional presenta algunas características que en su momento fueron objeto de crítica. La primera, y principal, es la asimilación al amparo. Si bien ambas figuras mantienen puntos de contacto, el amparo mantiene un carácter residual del cual carece el habeas data. En este mismo sentido, la legislación procesal del amparo ha sido particularmente restrictiva en lo referente a la apertura de la instancia, exigiendo el agotamiento de cualquier otro recurso o acción. La aplicación de las reglas del amparo a la nueva figura podría llevar a la falta de aplicación de la figura, transformándola en letra muerta.

Respecto al objeto de la garantía, el habeas data se separa de la consagración tradicional del derecho a la privacidad, al concentrarse en los efectos que la informática y la gestión documental tienen sobre el individuo. Al respecto, la garantía se ejerce exclusivamente sobre los ficheros públicos o privados destinados a proveer informes, con el fin de corregir o suprimir los registro que puedan ser considerados erróneos o directamente discriminatorios. Se trata, en suma, de una acción en extremo específica destinada a la prevención de abusos en el manejo de la información.

La ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Antecedentes legislativos:

Una vez incorporado a la constitución el instituto del habeas data por la reforma de 1994, fue necesario la reglamentación de la garantía constitucional, así como establecer el régimen por el cual se registrarán las bases de datos.

En realidad, la existencia de leyes que regulan la actividad de los bancos de datos existen desde hace décadas dentro de los países pertenecientes a Unión Europea. Si bien el primer antecedente de limitación se encuentra en la ley dictada por la República Federal de Alemania en referencia a la utilización de la información de los particulares por parte de la administración, la primera ley realmente relevante al respecto es el Convenio 108 del año 1981, el cual fue dictado por el Consejo Europeo, el cual inspiró la legislación de la mayoría de los países miembros de la por entonces Comunidad Económica durante la década de los ochenta. Este cuerpo legislativo ya preveía instituciones que luego se transformarían en estándares de la mayoría de normas que se dictarían de allí en más como ser la obligación de licitud y buena fe en la recolección de los datos, así como el principio de pertinencia o la regulación respecto a la transferencia internacional de los datos.

Para la década del noventa había quince estados miembros de la Unión Europea que contaban con legislación sobre bases de datos, entre los cuales podemos mencionar Alemania, Austria, España, Francia, Suecia o Dinamarca. Sin embargo, y a los efectos de lograr una uniformidad legislativa, el Parlamento Europeo nombró una comisión de expertos en el año 1990 a los efectos de confeccionar una nueva ley marco para todos los países miembros. Dicho instrumento legal fue aprobado en el año 1995, incorporándose como la Directiva 95/46 *“relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos”*. Esta directiva, si bien no es operativa para los países miembros, prevé sanciones y multas para aquellos que no adecuen su contenido a sus preceptos en un plazo determinado.

En la argentina, a partir del año 1994 se sucedieron varios intentos de legislación sobre los bancos de datos, llegándose a aprobar por parte de la legislatura la ley 24.745. la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1616/96. Entre las razones fundamentales de la decisión se adujo que el sistema de transferencia internacional de datos resultaba extremadamente complejo e impedía la transferencia internacional de datos al resto de los países de América Latina. Asimismo, la ley incluía una comisión bicameral con capacidades jurisdiccionales, lo que se consideró inconstitucional.

En realidad, aún durante el debate del proyecto del senador Menem que terminó siendo la ley 25.326, muchos participantes del mismo sostuvieron que no era necesario una ley particular para el sector. Fundamentaban la postura en el hecho que el instituto tenía ya rango constitucional, como asimismo en la idea que no se encontraba justificado la intromisión en un sector empresarial de fuerte crecimiento como eran los servicios de informes comerciales y las empresas de marketing directo.

En realidad, los argumentos esgrimidos no resistían un estudio demasiado prolongado. Si bien era cierto que el art. 43 consagraba el instituto, la ausencia de una reglamentación bien definida había hecho que muchas

acciones naufragaran tanto por el hecho de intentar proteger información no protegida, como por razones meramente procesales, atento el hecho que muchos jueces aplicaban las restricciones del amparo a los efectos de rechazar las demandas interpuestas ante ello. Al mismo tiempo, si bien era cierto que las empresas privadas ya se encontraban trabajando en el sector con un demostrable éxito económico, no era menos ciertos que la materia sobre la cual trabajaban involucraba directamente el interés público y las garantías constitucionales.

Como resultado de dicho proceso, se aprobó la ley 25.326 que regula no solo el procedimiento de habeas data sino también el régimen jurídico aplicable a la gestión de datos personales. En este sentido sigue muy de cerca el contenido de la ley española 5/92 de regulación del tratamiento automatizado de datos, dictada en 1992, que luego fue reformada en diciembre de 1999 para adecuarla a la directiva 95/46. En cuanto a su estructura, la ley establece una serie de principios generales en cuanto a objeto, sujetos aplicables y tratamiento de la información, para luego dedicar particular al régimen de los bancos de datos de informes comerciales y los destinados a marketing directo, dejando para el fin de la ley los aspectos relativos al control administrativo y las sanciones derivadas del incumplimiento del régimen.

Caracteres generales del tratamiento de datos personales.

A.- El Objeto:

El art. 1 de la ley especifica claramente cual es el objeto, definiéndolo como *“La protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos o cualquier medio técnico de tratamiento de datos sean estos públicos o privados destinados a proveer informes”*. De este modo podemos decir que **los objetos de la ley son en un primer aspecto. los archivos y bases de datos personales y por otro lado, el tratamiento que respecto al contenido de las mismas se realice**

El término tratamiento ha sido acuñado para hacer referencia a toda actividad que se realice sobre los datos protegidos por la ley. El objetivo de la utilización del concepto es evitar los daños derivados del mal uso de la información, con independencia de la forma técnica que la misma se realice.

Asimismo **la ley utiliza en forma indistinta los términos “archivo, registro, base y banco de datos”** y los define en el art. 2 como *“el conjunto organizados de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuera la modalidad de su formación, almacenamiento o acceso”*

Debe tenerse en cuenta que al igual que en el anterior art., la ley guarda una neutralidad tecnológica respecto a la forma de almacenamiento de los datos, de forma tal que cualquier medio conservación y recupero de la información entraría dentro de las previsiones de esta ley.

Del juego de ambos artículos podemos definir en forma clara cuales son **los datos incluidos en la ley**. La misma **será aplicable en principio a todos los datos personales contenidos en archivos destinados a proveer informes**. Sin embargo, existen excepciones que nacen, ya sea de la ley misma, ya de la legislación particular que regula a ciertas bases de datos. Estas son:

1.- Las bancos de datos destinados al uso particular: Nos estamos refiriendo a los archivos que no se encuentran destinados a prestar informes, siempre y cuando mantengan dicha característica, caso contrario, su titular comienza a ser responsable en los términos de la presente ley.

2.- Las bases de datos periodísticas: El art. 1 expresamente excluye la información periodísticas del régimen de la ley. Esto obedece a la preocupación manifestada ya en el debate en la convención constituyente de que la norma invadiera el secreto de las fuentes periodísticas.

3.- Los datos disociados: Son aquellos datos que, aunque naturalmente personales, fueron tratados de forma tal de hacer imposible la identificación del titular del datos. Es el caso de los datos estadísticos o todo caso en el que la recolección del datos se haga en forma anónima, tal como la encuesta.

4.- Las hipótesis de legislación especiales: Es el caso de ciertos ficheros que atento su importancia o estar comprometido funciones estatales fundamentales, cuentan con regulaciones particulares en referencia a su acceso y mantenimiento. Entre estos podemos nombrar el registro de reincidencia, el registro de la propiedad inmueble o incluso los registros públicos de comercia.

Los destinatarios:

Respecto a quien se encuentra obligado, ley 25.326 define al responsable del banco de datos como la persona que es titular de un archivo o registro, base o banco de datos. A este respecto debe decirse que si bien es regla de todas la legislaciones de bases de datos definir quienes, en caso de daño, deben responder, normalmente dicha imputación se realiza teniendo en cuenta la posibilidad de vigilancia o diseño de la base y no por su propiedad. Tal es la solución adoptada por el ordenamiento español y la directiva general 96/45 de la Unión Europea.

Nuestro ordenamiento, en cambio, se inclina por un criterio de responsabilidad basado en la propiedad de la base. De esta forma, y tal como ya habíamos dicho, es el sentido que debe darse al art. 2 cuando define al **responsable como el titular de un archivo, registro o base de datos**. Si bien es normal que el titular coincida con el gestor del banco de datos, entendiéndose a este como aquella persona con capacidad para tomar las decisiones respecto a la forma de explotación de la misma, no necesariamente este debe ser el caso. Tales hipótesis pueden plantear algunos interrogantes acerca de la causa de imputación de la responsabilidad civil, circunstancia que más adelante veremos.

Sin embargo, **el titular no es el único responsable** contemplado por la ley., noción que **se complementa con las figuras del usuario y el cesionario de los datos**. El mismo art. 2 define la figura del usuario como *“toda persona pública y privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en el archivos, registros o bancos de datos propios o de terceros o a través de la interconexión de los mismos”* El caso más común de esta figura es el caso de tercerización total o parcial de la gestión de los bancos de datos en una empresa con la libertad de acción suficiente como para trabajar por su cuenta. En tal caso, en el caso de que en el tratamiento de la información por el usuario se cometa algún tipo de infracción, la responsabilidad se desplaza del titular al tercero usuario de los datos.

Por último, los cesionarios, no se encuentran contemplados en el art. 2 de la ley como los otros dos sujetos obligacionales sino en el art. 11. El figura contempla a los terceros que reciben los datos por parte del titular de la base y en tal sentido son solidariamente responsables con este último por los daños y perjuicios que dicha transmisión pudiera ocasionarle al titular de los datos.

El beneficiario

La ley define al beneficiario como **el titular de los datos objeto de tratamiento**.

Tal como habíamos dicho anteriormente, la ley solo es aplicable a los llamados datos personales. En este sentido la ley otorga a la persona sobre quien refieren estos datos el carácter de titular de los mismos. Esto daría, en una primera lectura, la posibilidad de considerar que sobre los datos existe una relación de propiedad o por los menos un derecho de similares características. Sin embargo nada de esto es así. La mayoría de la legislación extranjera evita utilizar el término propiedad para referirse a los datos, lo mismo que la jurisprudencia que en más de una ocasión ha rechazado el concepto del habeas data como defensa de un derecho real sobre los datos. A este respecto veremos la cuestión con mayor detenimiento al analizar el bien jurídico protegido.

Una particularidad digna de mención, es que la ley argentina no diferencia entre personas físicas y jurídicas, como si hace la mayoría de la legislación europea y en particular la directiva 95/46. Esta es una solución a aplaudir, toda vez que si bien no podemos hablar de un fuero íntimo respecto a la sociedad o cooperativa, es indudable que las mismas pueden ser damnificadas en forma significativa por la publicidad de información errónea o restringida.

El Bien Jurídico Protegido

Si bien en una primera etapa la idea de los bancos de datos se vinculo casi exclusivamente con los problemas derivados de la privacidad, la evolución del fenómeno hizo replantearse dicha relación. La irrupción de las computadoras y la comunicación de masas planteó, como ya vimos, nuevos problemas a solucionar. En este sentido, la imagen corporativa o de un producto determinado, implica una inversión muchas veces importante en estrategias de comunicación, que puede verse frustrarse si información errónea o simplemente registringida se publicare. De la misma forma, los medio informáticos permiten hoy el entrecruzamiento de información que puede no significar una invasión a la intimidad de las personas, pero cuya sumatoria puede derivar en la confección perfiles sobre los titulares de dichos datos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta lo analizado en el párrafo anterior respecto a los sujetos protegidos por la ley, y notar la protección dada a las personas jurídicas, las cuales es claro que carecen de un fuero íntimo que proteger. Al mismo tiempo, la ley regula la información personal, cualquiera sea su contenido y sin importar si afecta o no la intimidad de su titular.

Si, como vimos anteriormente, no existe un derecho de propiedad sobre los datos, y no estamos protegiendo exclusivamente la intimidad ¿cuál es el bien jurídico protegido por la ley?

En realidad, este no es único, sino múltiple. La jurisprudencia alemana habla de un principio de **autodeterminación informativa**, entendiendo **el mismo como el derecho que tienen las personas a compartir a voluntad la información que sobre ellos se refiere**³. De esta forma, si bien el derecho a la intimidad se encuentra incluido, no es el único a considerar, incluyendo asimismo, el nombre, la misma identidad, la imagen personal, o el prestigio. Estos últimos elementos, en realidad, mantienen un contenido económico del que carece el concepto tradicional de intimidad

Principios Generales de la Ley de Bases de Datos:

Clasificación de los datos en la 25326		
Datos	Datos No Personales	Simples Datos
		Datos Disociados
	Datos Personales	Datos de Acceso Público
		Datos de Acceso Restringido
		Datos Sensibles

Los Datos Personales. Concepto. Clasificación:

La ley 25326 define a los datos personales en el art. 2 como: *“información de cualquier tipo sobre personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”*

En función de manifestado podemos definir que **no es información personal aquella que directamente no remita a persona alguna**. De esta forma, por ejemplo la información meteorológica o sobre cualquier tipo de fenómeno físico, no puede considerarse información personales. Es lo que, a falta de un mejor nombre, damos en llamar **simples datos**.

Pero al mismo tiempo, estos datos deben poder referirse a personas determinada o determinables. De esta manera, podemos excluir aquellos datos, que si bien se pueden referir a una persona, resulta imposible definir quien es el titular de los datos. Tal es el caso de la **información disociada**, hipótesis en la cual **los datos se separan de su titular, ya sea al momento de recolección o de su tratamiento, de forma que no es posible ya derivar a una persona determinada del contenido almacenado en el banco**. Ejemplos de esta modalidad son las bases de datos estadísticas en los casos que las mismas se refieran a actividades humanas, como por ejemplo, el consumo de alcohol o problemas médicos o incluso intenciones de voto.

Excluidos ambos casos, sin embargo, del análisis del texto de la ley parece claro que no todos los datos personales son tratados de la misma manera. En función de ello podemos diferenciar:

³ Sentencia del tribunal Constitucional Alemán sobre la ley de Censos, 1983, citado por Gils Carbo, Régimen Legal de las Bases de datos y Hábeas Data, La Ley, 2002. En el mismo sentido Cifuentes, “Acciones Procesales del art. 43 de la Constitución Nacional”, Revista Jurídica La Ley del 17-2-99

1.- Datos de acceso público: Son aquellos datos referidos a la identificación básica de las personas, función que se reputa básica para la vida social. El art. 5.2 de la ley define a los mismos como Nombre, apellido, domicilio, DNI, identificación tributaria o previsional, ocupación y fecha de nacimiento. Para el tratamiento de estos datos no es necesario el consentimiento previo del titular.

2.- Datos de circulación restringida: Son aquellos pasibles de tratamiento, a los que sin embargo se les exige el cumplimiento de los principios y prescripciones de la ley.

3.- Los datos sensibles: En este caso, se trata de datos relativos a la esfera más íntima de una persona, de forma tal que su tratamiento puede dar lugar casos de discriminación. En principio el tratamiento de estos datos se encuentra prohibido por ley a los particulares salvo las excepciones contempladas en la ley, las cuales analizaremos en el párrafo siguiente.

Los datos sensibles. Concepto. Régimen legal: Todos los ordenamientos de bases de datos consagran una categoría de datos, especialmente restringidos en su tratamiento, habida cuenta el hecho que su difusión fue conllevar la discriminación o por lo menos el desprestigio social de su titular.

El fundamento del instituto es proteger el derecho de expresión de las personas. La idea misma de una observación permanente de la conducta de un sujeto, más aun en el caso de su esfera más íntima, conlleva el efecto de restringir la libertad de las personas, las cuales se verían cohibidas a llevar a cabo sus deseos atento la condena social aparejada.

El segundo párrafo del art. 2 define a los datos sensibles como aquellos que *“revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o política e información referente a la salud o vida sexual.”*

El principal efecto que tiene la inclusión de cualquier dato dentro de esta categoría es que **la creación y gestión de una base de datos conteniendo este tipo de información se encuentra, en principio, prohibida**. El art. 7. 2 de la ley de bancos de datos, establece la prohibición genérica de recoger información *“que directa o indirectamente revele datos sensibles”*. Sin embargo este principio tiene sus excepciones:

1.- En caso de interés público: Este es el caso de registros policiales o de inteligencia. Debe tenerse en cuenta que esta excepción no implica privar de legalidad al tratamiento de los datos, ya que el art. 23 de la ley en un párrafo 2 claramente indica que las fuerzas de seguridad no podrán utilizar datos personales fuera de área de competencia específica de la institución y aún dichos casos debe realizarse de acuerdo a derecho.

2.- La Iglesia Católica, los partidos políticos, las asociaciones religiosas y sindicales: En tales casos, y por una cuestión funcional, estas instituciones se encuentran autorizados a recabar información sobre sus miembros. Sin embargo, dicha utilización se encuentra restringida a la institución y sus fines, quedando prohibida su cesión a terceros.

3.- Su utilización para fines estadísticos: Se trata de un caso de datos disociados, por lo que quedarían fuera del marco de la ley

4.- Datos relativos a salud: En los casos de utilización por parte de los profesionales intervinientes en el tratamiento del paciente (médicos, farmacéuticos, incluso enfermeros) es costumbre llevar constancia ordenada

de las tareas realizadas así como de los problemas de salud del individuo en cuestión. En este caso nos encontramos nuevamente frente a una excepción con fundamento operativo, al permitir el mejor tratamiento del paciente. Más allá de ello, esta información no solo se encuentra restringida por la legislación de bases de datos sino incluso su difusión no autorizada puede dar lugar a la comisión del delito de violación de secretos y responsabilidades derivadas del quebrantamiento de las reglas de ética profesionales de los colegios profesionales que pueden conllevar la expulsión de la matrícula.

Principios Generales de la Recolección y Tratamiento de la información

1.- Principio de licitud y lealtad en el tratamiento de datos personales

La ley de bases de datos establece la licitud y lealtad en el tratamiento de los datos personales en el art. 4.2 cuando ordena que la recolección de los datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a sus disposiciones y precisa que el tratamiento de datos es ilícito en los casos en que el titular no hubiera prestado consentimiento expreso e informado.

A estos fines la legislación contiene una detallada reglamentación respecto a la forma en que debe expresarse el consentimiento. De esta forma, es obligación no solo solicitar la misma sino que es necesario, asimismo, informar a los titulares cuál es el tratamiento que se les dará a los datos recolectados, incluidos los datos identificatorios de la base de datos (nombre, domicilio, identidad del titular), las características del tratamiento de la información (finalidad de la recolección, posibilidad de cesión a terceros) o incluso el carácter facultativo o no de la consulta. Todo esto lo veremos con mayor detenimiento al analizar el consentimiento.

El Principio de calidad de los datos:

El principio referido a la calidad de los datos exige que el responsable del banco de datos se comprometa activamente para que la información almacenada sea adecuada y actualizada, así como completa, esto último teniendo en cuenta los objetivos de la base.

Exige el art. 4.4 que los datos sean exactos y se encuentren actualizados, de forma tal que pesa sobre el titular del banco, la obligación de rectificación en caso de que los datos fueran falsos o caducos. Esto no impide en modo alguno que el afectado por los datos falsos inicie acciones de daños o perjuicios derivados de la falsa información.

Una obligación conexas con la presente es la de preservar los datos de manera que los terceros ajenos a la base puedan acceder a los mismos, con objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley.

El Principio de pertinencia:

El principio de pertinencia es el fundamento para la recolección de datos de terceros y, al mismo tiempo, el límite para el ejercicio del mismo. Tal como ha sostenido la jurisprudencia alemana en ocasión de fallar respecto a la ley de censos, si bien no existe un derecho de propiedad de los datos, la

recolección de los mismos no puede hacerse en forma libre, sino que debe obedecer a una razón socialmente aceptable. Atento ello, no es posible utilizar la información recolectada más allá de los objetivos manifestados al recogerla.

Esta restricción se vincula directamente con la existencia del requisito del consentimiento informado. A los efectos de lograr una efectiva protección del titular de los datos, la información sobre la cual toma la decisión debe ser vinculante para quien la emite: De esta forma, el gestor del banco de datos no puede apartarse de lo expresado al momento de la recolección de los datos, so pena de considerar que el tratamiento de los mismos no se adecua a los preceptos legales.

La ley de bases de datos consagra el principio de pertinencia en su art. 4.3 cuando sostiene que los datos que se recojan *“no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”*. En el mismo sentido, la legislación impone la carga de denunciar al momento de la inscripción de la base en el registro de la autoridad de control, los objetivos de la misma. Asimismo, el art. 6.a define a la finalidad como uno de los elementos a informar en el momento de solicitar el consentimiento.

Corolario de este principio es la obligación de restringir la recolección de información a la necesaria a los efectos de cumplir el objetivo propuesto para la base. De esta forma, la idea de la restricción en el tratamiento se refleja en una limitación en el momento mismo de la recolección, aumentando de esta manera la seguridad en el tratamiento de la información.

Principio de confidencialidad:

El principio de confidencialidad, contenido en el art. 10 de la ley, obliga a mantener el secreto respecto de la información contenida en el banco de datos e incluso aquella simplemente recibida en ocasión del tratamiento documental y confección de los registros.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el sujeto pasivo de esta obligación no es solamente el titular del banco de datos o el cesionarios sino que engloba a todos los partícipes de la explotación de los datos, sea cual sea la función que hayan cumplido, siempre y cuando hayan tenido acceso a los datos.

Sin embargo, este principio no es absoluto y modo de excepción el art. 10.2 exime de responsabilidad en los casos que hubiera una autorización judicial para revelar tales datos y en los casos en que mediare razones de seguridad pública, defensa nacional o salud pública.

Por último debe tenerse en cuenta que el art.32 de la ley incorpora el art. 157 bis en el código penal, el cual contiene una norma que incrimina la conducta consistente en revelar el contenido de un banco de datos en los casos en que hubiere obligación de guarda el secreto.

El consentimiento en la entrega de los datos

Una de la características particulares de la ley de bancos de datos es que regula en forma separada el consentimiento para el tratamiento de los datos y para su cesión. De esta manera, es posible autorizar la recolección de los datos pero no su cesión a terceros. Este se refleja en la ley en el mismo tratamiento legislativo, al normar en artículos separados ambas autorizaciones:

El art. 5 regula lo relativo a la recolección mientras que el art. 11 hace lo propio con la cesión a terceros

Tal como sostuvimos al analizar el principio de lealtad, es obligación del responsable del banco de datos solicitar la conformidad del titular de datos para su recolección. En este sentido, la ley sostiene en su art. 5.2 que la misma debe ser libre, expresa e informada.

El requisito de la libertad es, en realidad, redundante. Toda vez que el consentimiento constituye un acto jurídico, el mismo debe contar no solo con libertad sino también con intención y discernimiento, so pena de nulidad. En este sentido, ha sido un error del legislador la utilización del termino, habida cuenta que podría interpretarse, por exclusión, que el resto de elementos del acto jurídico no fueran necesarios.

Respecto al carácter expreso de la declaración, la misma por mandato legal debe realizarse por escrito. Esto implica desechar la posibilidad de que la misma sea realizada en forma tácita, so pena de nulidad. En este sentido, la ley tiende a ser mucho más severa que la legislación comparada que suele reservar el consentimiento escrito para los casos de datos sensibles.

En el mismo sentido el consentimiento debe ser manifiesto, por lo que debe tenerse en cuenta que en los casos que la autorización se realice en el marco de un contrato de adhesión, la misma debe imprimirse en forma destacada. La inclusión de la conformidad como un cláusula más, sin ningún tipo de signo identificadorio, puede llevar a su declaración de nulidad.

Respecto a la posibilidad de realizar la autorización en forma digital, la ley contempla la posibilidad cuando autoriza la suplantación de la forma escrita por cualquier otro medio equiparable. Sin embargo, en la actualidad y habida cuenta, la igualdad establecida por la ley de firma digital entre el documento digital y el realizado en soporte papel, esta previsión carece ya de sentido.

El tercer requisito del consentimiento es que el mismo sea informado. A este respecto, **el requerimiento del titular debe integrarse con el deber de información establecido en el art. 6 de la ley.** Así pues, al momento de solicitarlo el titular del dato debe conocer cual es la finalidad del banco, la identidad de los responsables de la base y los posibles cesionarios, así como del carácter obligatorio o no de la entrega de los datos, así como de los derechos de control, rectificación y opción de salida, en su caso.

El art. 5 define el consentimiento en la forma que vimos en los párrafos anteriores. Además, en el resto de los incisos plantea cuáles son las **excepciones** a la necesidad de autorización previa. Estas son:

1.- Datos que provengan de fuentes de acceso público: Son aquellos archivos, generalmente en manos del estados, respecto a los cuales cualquier interesado puede acceder. Ejemplo típico de ello, es registro de juicios realizado por las cámaras civiles o comerciales o el registro público de comercio.

2.- Datos requeridos por una función estatal o en los casos en que exista una obligación legal de entregarlos: Se trata de una aplicación del principio del poder de policía del estado, de forma tal el requisito del consentimiento cae en los casos en que el interés público se vea afectado.

Sin embargo, esto no quiere indicar que el estado tiene carta blanca a los efectos de confeccionar bancos de datos. Una de las primeras preocupaciones del estudio de régimen legal de los bancos fue precisamente

limitar el accionar del estado en este campo, otorgando mayor capacidad de control a los particulares. En este sentido la ley impide a los organismos estatales el tratamiento de la información que no sea necesario para el cumplimiento de las misiones legalmente impuestas a los mismos. (art. 23.2). Todo otra recolección debe ser reputada ilegal y es pasible de una acción de habeas data para su destrucción.

3.- Se trate de listados que contengan datos mínimos de identidad:

A este respecto se entienden que son: El nombre, el domicilio, la fecha de nacimiento, el documento de identidad, la ocupación y la identificación tributaria.

Al momento de la discusión en particular se ha eliminado el teléfono como dato mínimo. Esta solución parece acertada, toda vez que impide la intromisión en el hogar de los particulares de promotores o simples terceros. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia nacional ha sostenido que la intromisión telefónica constituye una violación a la privacidad, la cual puede generar responsabilidad civil.

4.- Casos que deriven de una relación contractual, científica o profesional anterior del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento: En este caso el consentimiento es accesorio a la relación principal, por lo que se entiende que, atento su carácter instrumental, el titular ha prestado su autorización al momento de acordar otro negocio jurídico. Es un caso de consentimiento tácito.

5.- Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes, conforme a lo normado por la ley de entidades financieras: Es un caso particular del inciso anterior: En este caso ya no es cualquier relación contractual sino solamente las establecidas con entidades bancarias y financieras. En realidad, es redundante y podría haberse eliminado, ya que se encuentra cubierto por el inciso anterior.

La autorización para cesión a los terceros:

El art. 11 al regular la cesión de datos a los terceros establece una serie de requisitos que esta debe cumplir a los efectos de considerar que la misma se realizó en legal forma. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que tanto el cesionario como el cedente deben cumplir con los principio de legalidad, calidad y pertinencia establecidos para toda base de datos. En función de ello, **el archivo de destino debe necesariamente tener un objeto lícito que admita el tratamiento de los datos cedidos.** Dicho de otro modo; el hecho que la recolección fue realizada por un tercero, no exime al cesionario de la obligación de respetar el fin para el cual se solicitaron los datos. En caso de violación de esta regla, los responsables de ambos bancos de datos responden solidariamente por lo daños causados.

El segundo requisito que marca la ley es la necesidad de un consentimiento específico que permita la cesión. Este requisito no se cumple simplemente con una autorización genérica, sino que es necesario la identificación de los posibles cesionarios o por lo menos los elementos para determinarlos. La ley en este sentido es claro y tacha de nulidad las autorizaciones realizada con ausencia de una finalidad específica o en los casos de personas indeterminada.

Respecto a la forma, si bien el art. 11 guarda silencio al respecto, debe interpretarse que deberá ser por escrito. El fundamento de esta solución es la regla establecida por el art. 5, la cual debe aplicarse analógicamente al presente caso.

Asimismo, el art. 11 al igual que el 5, establece los casos en que la cesión no necesita autorización previa. Son excepciones:

1.- Si media autorización legal: Se trataría en este caso de cuestiones de orden público y siempre que medie una ley especial al efecto.

2.- Si se realiza entre organismos del estado en forma directa, por vía de consulta o interconexión, con el limite que resulte de sus respectivas competencias: El fundamento de excepción se encuentra nuevamente en la necesidad de facilitar el cumplimiento de la función estatal y aumentar la eficiencia del mismo, permitiendo la interconexión de toda la administración. Sin embargo, al igual que la hipótesis de recolección, la competencia de cada repartición impone un límite funcional a los datos a los que se puede tener acceso.

3.- Datos relativos a salud: En los casos en que se encuentre en peligro la salud pública.

4.- Si se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información: En realidad se trata de un tipo de datos que queda fuera de la regulación de la ley y por tanto no es necesario control alguno, no solo respecto a la autorización.

Fuera del art. 11 es posible considerar otro dos supuestos como excepciones:

1.- Outsourcing de sistemas de información: En este caso, en realidad no hay verdadera cesión, toda vez que el supuesto cesionario se limita a realizar en interés del cedente el tratamiento de la información de la base de datos originaria. A diferencia de la cesión, en la cual hay dos bases de datos, aquí solo existe una: el cedente no entrega la información sino que encarga a un tercero el trabajo de tratamiento de la misma, el cual se realizará de acuerdo a la conformidad prestada al momento de la recolección de los datos.

2.- Informes crediticios: En este caso estamos frente a un caso de dato bipolar. Las empresas de informes, entonces, solamente necesitan la autorización de uno solo de sus titulares, normalmente el acreedor, para quedar eximidos de solicitarla también al deudor.

La obligación de inscripción de los bancos de datos personales:

La gran mayoría de los países que se han dictado un ordenamiento de bancos de datos, exigen a los titulares de los mismo su inscripción en un registro estatal, a los efectos posibilitar su control. En la práctica, la solución se mostró como costosa en función de los resultados conseguidos, siendo poco eficaz en la tarea de regulación encomendada. Es así que la Directiva 95/46 de la Unión europea limita los tipos de datos a notificarse e impulsa una reducción y simplificación de las comunicaciones del registro. Similar solución adoptan legislaciones más modernas como la belga o la irlandesa.

Más allá de ello, podemos diferenciar las soluciones adoptadas en el derecho comparado en dos grandes grupos. El primero, que podemos llamar restrictiva, constituye en una facultad discrecional del estado la capacidad de

autorizar o no la inscripción solicitada, realizando una autorización previa para el funcionamiento del banco. Tal es la solución adoptada por los ordenamientos más antiguos como los nórdicos que datan de fines de los 70.

La otra solución, de carácter más amplio, simplemente exige la inscripción de la base, sin otro requisito que la mera comunicación de sus principales características. Tal es la solución adoptada por la mayoría de las legislaciones modernas.

La legislación argentina impone el requisito de la inscripción previa para la licitud del tratamiento. La ausencia de la misma constituirá una violación pasible de sanción por parte de la autoridad de contralor. Una particularidad de la ley es que no solo incluye a las bases privadas sino también a las públicas, de forma tal que **todo tipo de banco de datos destinado a proveer informes esta obligado a su inscripción**

Respecto a la información a entregar por parte del usuario, la misma **debe contener por lo menos los siguientes items:**

- 1.- Nombre y domicilio del responsable
- 2.- Características y finalidades del archivo
- 3.- Naturaleza de los datos personales colectados
- 4.- Forma de recolección
- 5.- Destino de los datos.
- 6.- Forma del tratamiento y, en el caso de que la hubiera, de la interconexión de la base.
- 7.- Los formas de asegurar la seguridad informática
- 8.- Tiempo de conservación de los mismos.
- 9.- Formas de acceso y control por parte del titular de los datos.

Uno de los problemas más importantes a dilucidar, atento el hecho que la ley no es clara la respecto, es definir cuales son las facultades de la dirección de bancos de datos para negar la inscripción.

El art. 29.1.h de la ley dice que es facultad del director *“controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que debe reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a proveer informes”* En función de ello, parece claro que el control deberá ejercerse sobre los bancos privados. Sin embargo, cabe preguntarse si el mismo es un control meramente formal o puede existir un análisis de fondo.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la autoridad de aplicación, atento su carácter de funcionario público, tiene obligación legal de actuar de oficio en los casos de ilegalidad manifiesta. Por ello, no podría en modo alguno autorizar el funcionamiento de una banco de datos que contradiga claramente la normativa de fondo. Esto, sin embargo, no implica una facultad discrecional o la necesidad de una autorización previa, sino una mera aplicación del principio de legalidad debe revestir toda actividad de la administración pública.

Por todo lo dicho, podemos ver que **la solución adoptada por nuestra legislación es una solución mixta, permitiendo el análisis de fondo de la legalidad del banco pero restringiendo el mismo a los casos de flagrante violación de la ley.**

Los derechos del titular de los datos

El titular de los datos tiene respecto al titular de los datos los siguientes derechos:

- 1.- Derecho de Información
- 2.- Derecho de control y acceso
- 3.- Derecho de rectificación

El derecho de información:

El derecho de información tiene dos aspectos fundamentales. El primero, el cual se vincula con el consentimiento, obliga al titular del banco de datos a advertir sobre las características fundamentales de la base a los efectos de poder realizar una decisión fundada. Este tema fue analizado con mayor detenimiento en el momento de tratar el consentimiento, por lo que remitimos al mismo para su estudio.

En un segundo aspecto, todo sujeto de derecho tiene derecho a saber cuáles son los bancos de datos existentes, su finalidad y titulares. A este respecto, la autoridad de aplicación debe llevar un registro donde consten dichos antecedentes, según lo informado por los responsables al momento de la inscripción. Debe tenerse en cuenta que no toda la información suministrada al momento de la inscripción se verterá en dicho registro sino solo la finalidad del archivo y la identidad del responsable. Cualquier otro tipo de averiguación debe ser necesariamente dirigida al titular del banco de datos, por lo que el registro debe necesariamente mantener un domicilio actualizado de este último.

El derecho de acceso:

El derecho de acceso a la información, así como su derecho conexo, el de rectificación, son el fundamento de la acción constitucional de habeas data, la cual queda habilitada mediante la denegatoria de cualquiera de las prerrogativas antedichas.

El procedimiento de acceso comienza con la solicitud al titular del banco de datos. A este respecto debemos analizar cuáles son los sujetos autorizados para pedirla, así como la forma en la cual se deberá realizar.

Respecto a la legitimación para iniciar el reclamo, es, en primera instancia, solo el titular quien puede hacerlo. A dichos efectos, es necesario que el mismo acredite su identidad al momento de la solicitud, circunstancia que puede cumplirse simplemente con la presentación de su documento nacional de identidad.

En caso de ausencia o incapacidad, el titular de los datos puede ser suplantado por su representante, ya sea este convencional o legal en los casos de insania o si es menor de edad. Una particularidad de la ley, es que habilita la posibilidad de acceso a los sucesores universales de una persona fallecida, solución que se contrapone con el texto constitucional, el cual otorga el derecho de acceso solamente a los titulares directos, por considerar que los derechos personalismos no se transmiten a los sucesores universales.

Respecto de la forma, la ley nada define, por lo que debe considerarse que **estamos frente un caso de libertad de la formas**. Sin embargo hay que tener en cuenta que, a los efectos de iniciar la acción de habeas data, debe

demostrarse la presentación de la misma, por lo que es **conveniente realizar la solicitud de acceso mediante un medio fehaciente** (carta documento, nota con cargo de recepción, etc.)

Respecto a los efectos, **la solicitud de informes implica el comienzo del plazo para contestar la misma**, el cual en la ley argentina es de **10 días**. **Vencido dicho plazo se habilita la instancia judicial del habeas data**. Por lo dicho, debe tenerse en cuenta que la falta de solicitud al titular del banco puede derivar en el rechazo de la demanda *in limine*, La excepción a esta regla son los casos en que exista un peligro claro en la demora o sea imposible la interposición de la solicitud, lo cual debe ser probado por el demandante.

La contestación de la solicitud debe ser clara y completa, de forma tal de incluir toda la información que sobre el solicitante existiera en el banco, más allá de que la solicitud se hubiera realizado en forma parcial o solamente respecto a un aspecto de la información contenida en el banco. Respecto a la forma, nuevamente nos encontramos ante un caso de libertad de formas, por lo que puede optarse por contestar en el soporte que se desee, aunque sin embargo hay que tener en cuenta la cuestión probatoria respecto a la satisfacción del pedido.

Los límites respecto al contenido de la información son básicamente dos: El primero, que la contestación no puede divulgar información referente a terceros distintos al titular de los datos. Esto, por supuesto, se refiere a los datos contenidos en el banco y no a los terceros que participaron en el tratamiento de la información, actividad que no se encuentra cubierta por el derecho de privacidad.

El segundo límite es que la respuesta debe basarse en las constancias del archivo: El habeas data no tiene el alcance de imponer a los responsables de archivo la búsqueda o averiguación respecto al objeto de la consulta. Esta cuestión se planteó respecto al pedido de los familiares de los desaparecidos para tener acceso a los registros de las Fuerzas Armadas para conocer el destino final de los secuestrados. Ante la negativa de los organismos oficiales respecto a la existencia de archivos, lo único que resta hacer al juez es ordenar un reconocimiento judicial para verificar la autenticidad de la respuesta, pero no puede obligar, por lo menos mediante un habeas data, a que realice una investigación para establecer el paradero.

Con respecto a los costos de la gestión los mismo son gratuitos, siempre que la petición se haga en intervalos no mayores a seis meses el uno del otro. En caso que el lapso fuera menor, el consulta tendrá un costo definido por el titular del banco, salvo que exista razones suficientes que ameriten un nuevo informe en tal corto plazo.

Derecho de rectificación:

La constitucional nacional consagra el derecho de las personas a rectificar, suprimir, actualizar o dar confidencialidad a los datos propios en caso de falsedad o discriminación. La ley 25326 aumentó los beneficios de los titulares de los datos, al obligar a los responsables de los bancos a cumplir los principios de calidad, pertinencia y licitud en el tratamiento de los datos. De allí que las posibilidades de rectificación en los registros hayan aumentado con la sanción de la ley. Sin agotar la casuística, los principales casos son:

1.- Rectificar datos falsos, erróneos o inexactos: Es un caso contemplado por el art. 43 de la constitución nacional y es, quizás, el caso más típico de habeas data.

2.- Suprimir los datos que fueren inadecuados o impertinentes: En este caso no sólo se contempla el caso de datos discriminatorios, sino todos aquellos que sin llegar a serlo, constituyan datos sensible o que hubieran sido adquiridos mediante mala fe o no cumplan con el principio de pertinencia.

3.- Actualizar los datos obsoletos o vetustos: En este caso la pretensión solo reviste interés para el titular de los datos en los casos en que pueda derivarse un daño de la desactualización de los mismos, como es el caso de un registro destinado a brindar informes sobre el crédito. En cambio en los casos de empresas destinadas al marketing directo, el único perjudicado serían las empresas que utilizan el servicio.

4.- Integrar o adicionar la información que estuviera incompleta: Podemos considerar al dato incompleto en los casos en que la omisión de algún detalle modifica de manera sustancial el significado de la información. Si bien esta hipótesis no esta contemplada en la ley, es asimilable al dato erróneo y debe aplicarse su régimen por analogía.

Reciba la petición de rectificación, respecto a cuya forma es aplicable lo dicho en referencia al pedido de acceso, el titular del banco de datos tiene cinco días para rectificar el error. En el caso de entender que no hay razón para corregir los datos, debe comunicárselo en el mismo plazo al titular del dato, el cual a partir de ese momento tiene la posibilidad de iniciar las acciones judiciales del habeas data.

Mientras se resuelve el pedido el responsable del banco de datos tiene la obligación de señalar la controversia sobre la información. A estos fines, puede optar por colocar una nota al misma señalando este carácter o simplemente restringir el acceso.

Con respecto a los costos del proceso, los mismos son absolutamente gratuitos.

El Habeas Data. Presupuestos Materiales.

De acuerdo a Palazzi, el hábeas data puede ser definido como una acción judicial para acceder a registros o bancos de datos, conocer los datos almacenados y en caso de existir falsedad o discriminación corregir dicha información o pedir su confidencialidad.

Como ya analizáramos el instituto se encuentra consagrado en el art. 43 junto con la garantía del amparo. La norma constitucional no define cuales son los bienes jurídicos protegidos por el instituto, lo que ha permitido a la doctrina ampliar la protección desde el concepto primigenio de privacidad al principio de autodeterminación informativa, incluyendo de esta forma datos que no afecten directamente el fuero íntimo, como la identidad o la imagen corporal.

En esta inteligencia el art. 33 de la ley de bancos de datos ha ampliado el contenido de la acción a los casos en que se produzca, no ya una invasión a la privacidad sino simplemente en los casos de violación de los preceptos legales analizados. Tal como expresa la letra de la ley la acción de protección

de datos procederá “...en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización”

Esta ampliación del ámbito de actuación de la figura conlleva un cambio sustancial en los presupuestos del ejercicio de la acción. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el fin primario de la acción de habeas data es tomar conocimiento de los datos personales contenidos en los registros. La modificación, rectificación y supresión de los mismos puede o no acumularse a la pretensión, debiendo en tal caso el actor cumplir con la carga de la prueba respecto a la antijuridicidad del tratamiento del dato.

Los presupuestos para la procedencia de la acción son los siguientes:

1.- Que el dato sea personal: Los datos deben ser relativos a una persona determinada o determinable. En tal sentido me remito a analizado anteriormente al respecto.

2.- Que el banco de datos este destinado a la provisión de informes a terceros: Los datos tienen que estar asentados en bancos con la potencialidad de ser conocidos por terceros. Al respecto, el criterio de interpretación ha sido amplio, entendiendo la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que incluso los sistemas de control de inventario y proveedores deben ser registrados por ser pasibles de acceso por la autoridad impositiva.

3.- Interés legítimo en el acceso: La parte debe manifestar razones legítimas para intentar el acceso. A este respecto la sanción de la ley 25.326 ha ampliado en forma sustancial el interés jurídico protegido. El contenido del art. 33 de la ley 25.326 nos permite apartarnos del criterio tradicional de intimidad consagrado en Ponzetti de Balbín, evitando limitar a los datos categorizados como sensibles.

En similar inteligencia tampoco es necesario acreditar la existencia de un perjuicio. La ley de bancos de datos ha determinado que no es necesario acreditar la existencia de un daño actual, bastando la mera sospecha o amenaza a los derechos del titular del dato. En este sentido, Ekmedjian sostuvo que el habeas data procede no solo contra datos falsos o discriminatorios sino asimismo contra aquellos que se han tornado obsoletos o incompletos, por lo que el accionante no necesita demostrar un perjuicio específico.

4.- Inexistencia de otra vía idónea para hacer valer los derechos: La amenaza debe provenir de la registración del dato y el derecho a modificarlo o suprimirlo debe ser de sencilla acreditación. Debe tenerse en cuenta que el habeas data constituye una vía de excepción, de carácter sumarísimo, por lo que excede a su marco la posibilidad de su utilización para plantear un debate sobre situaciones que deban ser ventiladas en un proceso de conocimiento o que por disposición legal o reglamentaria estén sometidas a otro procedimiento específico.

Procedimiento

Legitimación: El texto constitucional atribuye la acción a toda persona cuyos datos sean referidos en un archivo. En tal sentido se discutió la naturaleza de derecho personalísimo del instituto, toda vez que dicha

caracterización impediría el ejercicio de la acción por otra persona que el afectado directo.

La ley 25326 aclaró la cuestión al establecer que se encuentran legitimados para actuar:

El titular de los datos: es decir toda persona física o jurídica cuyos datos sean objeto de tratamiento de datos

Los tutores o curadores de menores o incapaces: Dentro de ellos debemos incluir a los padres respecto de sus hijos menores de edad, en su carácter de representantes legales.

Los sucesores de las personas físicas, en línea directa o colateral hasta segundo grado.

Con respecto de la legitimación pasiva, el destinatario de la acción es el titular del banco de datos. Del mismo también pueden ser demandados los usuarios del banco, entendiendo a los mismos como toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de los datos.

Un caso particular se produce respecto de las empresas de informes comerciales en los casos que el dato impugnado provenga de un tercero, ya sea una entidad financiera o el propio Banco Central. Alguna jurisprudencia ha entendido que en tales casos, existe un caso de falta de legitimación pasiva respecto de la empresa, debiendo entablarse la acción contra el proveedor del dato.

Tal postura no resulta acorde con lo establecido por la ley de bancos de datos. La empresa de informes comerciales, en tanto titular del banco, se encuentra obligada a mantener un estándar de calidad de los datos que trata, con prescindencia de la fuente de la que lo obtuvo, circunstancia que habilita la legitimación pasiva de la acción.

Competencia: La competencia consagrada por la ley 25326 en su art. 36 es amplia pudiendo el actor optar por interponer la demanda ante el juez de:

Su domicilio

El domicilio de la actora

El lugar donde se produjeron los hechos o pudieran tener efectos.

Debe tenerse en cuenta que en los casos de entablarse una acción contra archivos públicos pertenecientes a la nación, la competencia se torna federal en razón de las personas involucradas.

Procedimiento: El art. 37 de la ley establece que el procedimiento se regirá por las previsiones contenidas en la ley, aplicándose en forma supletoria, las reglas del amparo y las correspondientes al proceso sumarísimo.

La 25.326 establece en forma pormenorizada tanto el procedimiento de intimación como el trámite judicial posterior, por lo que la aplicación supletoria se limita a cuestiones accesorias referentes a la prueba y recursos posibles. En este sentido, Gils Carbo rescata las siguientes reglas:

1.- La prueba debe ser solicitada con la demanda, acompañándose la documental con el escrito de inicio.

2.- En caso de peticiones manifiestamente improcedentes, el juez puede ordenar el rechazo in limine

3.- Es improcedente la recusación sin causa, como asimismo no pueden articularse incidentes ni excepciones previas

4.- Los plazos son de 3 días con excepción del plazo de presentación del informe que es de 5.

5.- Solo serán apelables la sentencia definitiva, la resolución de rechazo y las que dispongan medidas precautorias.

Respecto de la acción en sí, la misma queda sujeta a un requisito formal que es la solicitud extrajudicial previa al titular del banco de datos, requisitos de que ya hemos hablado al tratar el derecho de acceso. Sin embargo, la ausencia de intimación puede no implicar el rechazo de la demanda. Si el juez otorga el traslado de la acción, la pasiva no puede excepcionarse con fundamento en la ausencia de intimación, debiendo producir el informe que corresponde, el que si resulta satisfactorio implicará la condena en costas del demandante.

Si el juez da curso a la demanda, ordenará que se remita la información concerniente al accionante y podrá solicitar detalles sobre el soporte informático, así como la documentación respaldatoria y cualquier otro aspecto que estime conveniente.

El responsable del registro tiene cinco días para producir el informe, el cual debe cumplir con las exigencias establecidas por el art. 41 de la ley 25326:

a.- Expresar las razones por las que se incluyó la información cuestionada.

b.- Explicar las razones por las que omitió satisfacer los pedidos extrajudiciales de acceso.

c.- La información suministrada debe ser completa y clara, versando sobre la totalidad de las constancias que sobre el accionante se posea. Respecto al formato el art 15 inciso 3 permite la amplitud de las formas, por lo que no habría problema presentarla en formato digital, máxime considerando que la ley 25.506 de firma digital permite dar por cumplido el requisito de escritura por este medio.

Luego de producido el informe, se ordenará traslado a la actora por el plazo de tres días, a los efectos de que la misma solicite la rectificación de los datos de así considerarlo necesario. Esta petición debe realizarse por escrito, en forma fundada y de la misma se correrá traslado a la demanda por el término de 3 días.

Una vez cumplida dicha etapa procesal o en los casos que se hubiera vencido el plazo de presentar el informe sin que se diera satisfacción al pedido, el juez dictará sentencia.

El contenido de la sentencia variará según se haya solicitado la rectificación de los asientos o no. En el primer caso, el juez ordenará las modificaciones solicitadas en caso de considerar que correspondan a derecho. En la segunda hipótesis la sentencia limitarse a declarar cumplida la finalidad de la acción y determinar las costas del proceso.

En los casos de demandados remisos, el juez podrá ordenar la aplicación de astreintes, ya sea con el fin de permitir el acceso de los datos en el caso de la omisión del informe, ya sea para que el titular del dato modifique los datos.